

1500109-03.2022.8.26.0540

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, que o agravante se dedica ao tráfico de drogas, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Maua-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500109-03.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2009756/2022 - DEL.POL.MAUA, 22390874 - DEL.POL.MAUA, 3/22/116 - DEL.POL.MAUA, 3/2022 - DEL.POL.MAUA, 2009756 - DEL.POL.MAUA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUIS ALBERTO MASSELLI

Data da Audiência:

10/02/2022

Em 10 de fevereiro de 2022 às 14h30, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réu privado de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Dra. Fabíola Castilho Soffner. Presente o réu Luis Alberto Masseli, citado em audiência.

Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presentes as testemunhas Adilço Gomes Negrão e Anderson Barbosa Muro. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, Iniciados os trabalhos, pela defesa foi dito: "A Defesa nega os fatos, sendo o acusado inocente, o que restará comprovado provado ao final da instrução. Arrola-se as mesmas testemunhas indicadas pela acusação." Pelo MM. Juiz foi decidido: Há justa causa para a ação penal, posto que a quantidade de substância entorpecente apreendida é compatível com a denúncia de tráfico de drogas. Quanto à prova de materialidade, o laudo de constatação encontra-se complementado pelo laudo de exame químico toxicológico juntado aos autos. Assim, recebo a denúncia oferecida em desfavor do acusado. Concedo ao acusado os benefícios da justiça gratuita. Anote-se."A seguir, foram inquiridas as testemunhas presentes, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. A seguir, pela Defesa foi dispensada nova conversa com o acusado antes do interrogatório. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. LUIS ALBERTO MASSELLI, qualificado às fls. 20 e 22, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 11 de janeiro de 2022, por volta das 15h:25min, na Rua Antônio Ambrósio, nº 228, Jardim Eden, nesta cidade e comarca de Mauá, para fins de tráfico, guardava, trazia consigo, expunha à venda e vendia, 02 invólucros plásticos contendo 33 gramas de Tetrahydrocannabinol (THC), conhecido por maconha (Item 1), 33 invólucros plásticos contendo 27,9 gramas de cocaína (Item 2), e 39 microtubos plásticos do tipo eppendorf contendo 5,6 gramas de cocaína, na forma de crack (Item 3), substâncias entorpecentes ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, laudo de constatação de fls. 14/16 e laudo toxicológico definitivo de fls. 81/83 (fls. 68/69). Foi convertida a prisão em flagrante do acusado em preventiva (fls. 48/50). A denúncia foi oferecida (fls. 67). Foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 71/76). O réu foi notificado (fls. 95), apresentou defesa preliminar (termo de audiência), a denúncia foi recebida (termo de audiência) e o recebimento foi mantido (termo de audiência). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as testemunhas Adilço Gomes Negrão (gravação audiovisual) e Anderson Barbosa Muro (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Luis Alberto Masselli (gravação audiovisual). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Adilço Gomes Negrão (fls. 3) e Anderson Barbosa Muro (fls. 4) e o réu Luis Alberto Masselli (fls. 5). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Luis, em debates, requereu a improcedência da ação ou a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no máximo, o regime aberto, a substituição por penas restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1 e 2). Auto de

exibição e apreensão (fls. 11/12). Laudo de constatação provisória (fls. 14/16). Fotos das drogas, do réu e do local dos fatos (fls. 24/29). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 81/83). Folha de antecedentes (fls. 45/47 = 77/79) e certidão (fls. 43/44). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo de constatação provisória (fls. 14/16), fotos das drogas, do réu e do local dos fatos (fls. 24/29), exame químico toxicológico definitivo (fls. 81/83) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. Em juízo, a testemunha Adilço Gomes Negrão disse que: a) me recordo da ocorrência dono dia 11 de janeiro de 2022; b) na Rua Daniel Ambrósio, é conhecida por Viela da Curva; c) lá há vielas; d) foi feita uma campanha de viatura descaracterizada, por 10 minutos, há 50 metros, nem precisou fazer uso de binóculo, e vimos ele servindo três usuários; e) eu fui onde estava a sacola com drogas e 2 porções de maconha, 33 porções de cocaína e em torno de 40 porções de crack, além dos R\$ 55,00 que estavam nas vestes dele; f) ele mexia numa sacola preta, no cantinho do beco, que ela pegava e entregava aos usuários; g) ele disse que não estava traficando e havia saído da prisão; h) não me recordo se as outras prisões foram no mesmo local, porque não fui eu que o prendi, provavelmente foi lá; i) a sacolinha com as drogas estava em um buraco na parede; j) eu já conhecia ele, não havia prendido ele, mas ele estava na Delegacia, porque havia sido preso pelos policiais pelo mesmo artigo; k) eu não tenho nada contra ele e ele não tem nada contra mim, inclusive quando ele estava na cela, eu orientei ele a sair desta vida, porque ele tem família (gravação audiovisual e fls. 3). A testemunha Anderson Barbosa Muro, sob o crivo do contraditório, disse que: a) eu me recordo da ocorrência; b) nesse dia, eu, o meu parceiro e os demais policiais desta Delegacia fomos até o local, onde sabemos que ocorreu o tráfico de drogas e já houveram flagrantes lá; c) fizemos uma campanha e vimos três pessoas o procurarem, ele ia até a fenda de uma parede, pegava algo, entregava a estas pessoas e recebia algo; d) abordamos ele e encontramos R\$ 55,00 em notas diversas; e) o meu parceiro encontrou na fenda desta parede uma sacola preta com as drogas; f) ele apenas negou; g) eu conhecia o réu, porque ele foi preso pela nossa Delegacia, em outra biqueira e parece que nesta biqueira também; h) a campana foi há aproximadamente por 50 metros, por 10 minutos, sem o uso de binóculo; i) o policial de nome Marcelo também estava nesta diligência; j) eram 2 porções de maconha, 33 porções de cocaína e 39 porções de crack; k) acredito que o Marcelo não tenha nada contra o réu (gravação audiovisual e fls. 4). Por fim, o réu Luis Alberto Masselli, ao ser interrogado em juízo, disse que: a) os fatos não são verdadeiros; b) eu sou dependente químico e fumo crack; c) eu trabalhei como servente de pedreiro ganhei R\$ 65,00, paguei R\$ 5,00 da passagem e tinha R\$ 59,00 em meu bolso; d) eu fui comprar drogas, o traficante não estava lá e os policiais me prenderam; e) eu não tenho nada contra os policiais; f) os policiais não tem nada contra mim e o Marcelo que foi o que me abordou e ele me chama pelo nome de Luis quando em encontra na loja, mas eu não tenho nada contra o Marcelo, nem ele contra mim; g) quem me abordou foi o policial Marcelo (gravação audiovisual e fls. 5). Pois bem, pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo de constatação provisória (fls. 14/16), fotos das drogas, do réu e do local dos fatos (fls. 24/29), exame químico toxicológico definitivo (fls. 81/83), como também pelos depoimentos das testemunhas Adilço Gomes Negrão (gravação audiovisual e fls. 3) e Anderson Barbosa Muro (gravação audiovisual e fls. 4), foi comprovado que as testemunhas, que são policiais civis, estavam realizando diligências no local dos fatos, que já era conhecido por ser ponto de venda de entorpecentes, momento em que observaram o réu Luis na viela, pegando algo em um buraco na parede, entregando aos usuários que ali compareciam, recebia, algo dessas pessoas e deixavam o local rapidamente, e apreenderam R\$ 55,00 no bolso da calça dele e em uma sacola plástica escondida na fenda da parede a quantia de 2 porções de maconha, pesando 33g; 33 porções de cocaína, pesando 27,9g; 39 porções de crack, pesando 5,6g. A autodefesa do réu restou sem credibilidade, além de que ele cita o nome de um policial que se chama Marcelo, mas disse categoricamente não ter nenhuma desavença contra o réu, nem o policial Marcelo contra ele, em suma, o fato do policial conhecer o réu de outras prisões, por si

só, não macula o depoimento desse agente policial. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Luis Alberto Masselli, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (02 porções de maconha, pesando 33g, 33 porções de cocaína, pesando 27,9g, e 39 porções de crack, pesando 5,6g – fls. 11/12, 14/16 e 81/83) não permitem aumentar a pena, como também as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 45/47 = 77/79 e 43/44). Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem apreciadas. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento a serem apreciadas, contudo reduz a pena em 2/3, passando para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa. Ressalto que entendo que poderia me utilizar da natureza e da quantidade das drogas, para fins de redução de pena do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, por não haver outro parâmetro de redução, entre 1/6 e 2/3, contudo o Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 712, seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.887.511/SP, passaram a entender que não é possível a utilização da natureza e da quantidade das drogas na terceira fase de aplicação da pena, por esta razão reduzi a pena no máximo de 2/3. Inclusive, no processo nº 1500527-09.2020.8.26.0540, que tramita nesta Vara (fls. 318/325), foi determinado que este magistrado recalculasse a pena com base nestes parâmetros. Desta maneira, por segurança das relações jurídicas, passo a dosar a pena, conforme a mencionada orientação dos Tribunais Superiores. Não levei em consideração os processos em andamento para afastar o mencionado redutor, porque ora o Supremo Tribunal Federal admite o redutor (HC 177670 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 22-09-2020 PUBLIC 23-09-2020), ora o afasta (HC 190946 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 13-08-2021 PUBLIC 16-08-2021), o mesmo ocorrendo com o Superior Tribunal de Justiça, ora afastando o redutor (AgRg no HC 684.984/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021), ora o admitindo (AgRg no AREsp 1867011/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021; HABEAS CORPUS Nº 669511 - SP - 2021/0161887-8 - Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2021), por isso, em obediência ao mencionado postulado da segurança das relações jurídicas, não levo ele em consideração, como o vinha fazendo. No caso do tráfico de drogas, o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 determina que o juiz “na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente” – (grifei). Ou seja, a fixação da pena compreende a dosimetria e o regime inicial de cumprimento, tanto que o legislador ressaltou que a natureza e a quantidade das drogas e a conduta social preponderam sobre o artigo 59 do Código de Processo Penal, e este artigo (59 do Código de Processo Penal) deve ser considerado na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, conforme prevê o artigo 33, § 3º, do Código de Processo Penal. Desta maneira, fixo o regime inicial de cumprimento da pena semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, a despeito de a pena ser inferior a quatro anos e o réu não ser reincidente (fls. 43/44 e 45/47 = 77/79), a natureza e quantidade das drogas apreendidas (02 porções de maconha, pesando 33g, 33 porções de cocaína, pesando 27,9g, e 39 porções de crack, pesando 5,6g – fls. 11/12, 14/16 e 81/83), preponderam sobre o artigo 59 do Código Penal, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, e o artigo 59 do Código Penal deve ser levado em consideração na dosimetria da pena, segundo preceitua o artigo 33, § 3º, do Código Penal. Neste sentido a jurisprudência: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENA E RECUSA DE ENVIO À PGJ. RECUSA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELO PARQUET. ANUÊNCIA DO MAGISTRADO. PROPOSTA DE REVISÃO REQUERIDA A DESTEMPO PELA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser

utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 20/2/2020; HC 180.365-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 27/3/2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 17/9/2019 e HC 174184-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FÉLIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe de 3/4/2018.

2. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal para certos tipos de crimes, principalmente no momento presente, em que se faz necessária a otimização dos recursos públicos. Com efeito, o membro do Ministério Público, ao se deparar com os autos de um inquérito policial, a par de verificar a existência de indícios de autoria e materialidade, deverá ainda analisar o preenchimento dos requisitos autorizadores da celebração do ANPP, os quais estão expressamente previstos no Código de Processo Penal: 1) confissão formal e circunstancial; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e 3) que a medida seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

3. Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto.

4. Conforme o acórdão ora impugnado, o requerimento de revisão do não oferecimento de proposta do ANPP, para fins de análise do órgão superior do Ministério Público local, ocorreu a destempe pela defesa, deixando que a instrução criminal fluísse regularmente.

5. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a quantidade e a qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.

6. No caso, embora estabelecida a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão, a quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos (62 porções de cocaína, contendo 55,63g; 04 pedras de crack, contendo 0,41g; e 63 porções de "maconha", contendo 132,64g), utilizadas na escolha do patamar de diminuição do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, o semiaberto, em razão da quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos.

7. Habeas corpus não conhecido." - (grifei). (HC 612.449/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020). "PENAL. AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAFASTÁVEL A INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. IMPOSIÇÃO JUSTIFICADA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. PRECEDENTES DO STJ. AGRADO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte a quo afastou a aplicação a minorante considerando as circunstâncias fáticas da causa, qual seja, a quantidade e variedade das drogas apreendidas. Entender de forma diversa exigiria, necessariamente, incursão na matéria fático-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. A quantidade e natureza das drogas apreendidas - 18,7g de cocaína e 348,5g de Cannabis sativa - constituem fundamentos idôneos para o agravamento do aspecto

qualitativo da pena, ou seja, para a fixação de regime mais gravoso, no caso o semiaberto. 3. Tendo a reprimenda ultrapassado os 4 anos de prisão, a circunstância judicial desfavorável (quantidade da droga) justifica a fixação do regime inicial semiaberto, segundo a jurisprudência desta Corte. 4. Agravamento regimental desprovido." - (grifei). (AgRg no AREsp 1671723/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 27/7/2012, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. III - Ademais, a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta requer fundamentação específica, baseada em elementos concretos extraídos dos autos. Inteligência das Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719 do STF. IV - No caso, aplicada a pena de 2 anos de reclusão, entendendo que deve ser estabelecido o regime inicial intermediário, nos termos do art.33, § 3º, do Código Penal, e do art.42 da Lei de Drogas. A quantidade e variedade dos entorpecentes podem ser utilizadas como fundamento a ensejar a aplicação do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06. V - O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o HC n. 97.256/RS, reconhecendo a inconstitucionalidade da parte final do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, passou a admitir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. VI - Na hipótese em análise, a quantidade e diversidade das drogas apreendidas (195,6g maconha, 63,9g de cocaína, 17,1g de crack e mais 118g de cocaína) não recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, consoante o disposto no art. 44, inciso III, do Código Penal, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na negativa da benesse em tela. Habeas corpus não conhecido. Ordem de ofício apenas para fixar o regime semiaberto para resgate da reprimenda, mantido os demais termos da condenação." - (grifei). (HC 581.356/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020). "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO ADEQUADO. AFASTAR CARÁTER HEDIONDO. PLEITO PREJUDICADO. DETRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Concluído pelas instâncias antecedentes, com fulcro nos elementos constantes dos autos e no fato de registrar atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, que o agravante se dedica ao tráfico de drogas, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas.

Precedentes. 4. Embora o agente seja primário e a pena reclusiva tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento das sanções impostas, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade e natureza de entorpecente), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 5. Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos de reclusão, é inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a ausência de preenchimento de requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal). 6. Fica prejudicado o pleito de afastamento do caráter hediondo do delito, pelo não reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado. 7. Noticiado o trânsito em julgado da ação penal, caberá ao Juízo de execução penal averiguar a possibilidade de estabelecimento de regime mais brando diante do desconto do período em que o agravante permaneceu preso preventivamente. 8. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 573.149/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020) - (grifei). Não substituo a pena do réu, porque, nos termos do artigo 44, § 3º, do Código Penal, não é socialmente recomendável, pela natureza e quantidade das drogas (02 porções de maconha, pesando 33g, 33 porções de cocaína, pesando 27,9g, e 39 porções de crack, pesando 5,6g - fls. 11/12, 14/16 e 81/83), fato concreto que impede a substituição. Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 18/19). Determino o perdimento do valor apreendido nos autos (fls. 11/12), em favor da União, porque se trata do produto do crime, segundo dispõe o mencionado artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. Por fim, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 11/12, 14/16 e 81/83). III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO o réu LUIS ALBERTO MASSELLI (R.G. nº 42.077.544 - filho de Eliane de Lourdes Masselli - fls. 20 e 22), pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 166 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pois tão presentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, o réu aguardou todo o trâmite processual preso (fls. 48/50). O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Oficie-se imediatamente ao estabelecimento penal, no qual o réu está preso provisoriamente para transferi-lo ao regime adequado, nos termos do Súmula vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência do valor decretado perdido ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD; b) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; c) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; d) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; e) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Autorizo a extração de cópias. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados." Pelo Dr. Defensor Público e pelo réu foi dito que manifestam o desejo de recorrer da Sentença proferida, requerendo a defesa vistas após expedição da guia provisória. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso requerido pela Defensoria Pública e pelo réu. Dê-se vistas dos autos à Defensoria para apresentação das razões após expedição da guia provisória. Intime-se pessoalmente o Ministério Público, nos termos da lei. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.